

第4節 構成要件の故意と事実の錯誤

刑法
No40

予備独自問題 H25-7

(配点: 3)

月 日
月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 暴力団組長甲は、配下組員乙に対し、「もし、Aがこちらの要求を聞き入れなかったら、Aを殺してこい。Aがこちらの要求を聞き入れるのであれば、Aを殺す必要はない。」旨指示し、乙にけん銃を手渡した上、乙を対立する暴力団組員Aのところに行かせた。乙は、Aが要求を聞き入れなかったので、Aをけん銃で射殺した。甲には殺人罪の故意が認められる。
2. 甲は、駐車場で他人の所有する自動車に放火し、公共の危険を生じさせた。その際、甲は、公共の危険が発生するとは認識していなかった。甲には建造物等以外放火罪の故意は認められない。
3. 甲は、乙から、乙が窃取してきた貴金属類を、乙が盗んできたものかもしれないと思いながら、あえて買い取った。甲には盗品等有償譲受け罪の故意が認められる。
4. 覚せい剤が含まれている錠剤を所持していた甲は、同錠剤について、身体に有害で違法な薬物類であるとの認識はあったが、覚せい剤や麻薬類ではないと認識していた。甲には覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪の故意が認められる。
5. 甲は、Aを殺害しようと考え、Aに向けてけん銃を発射し、弾丸をAに命中させ、Aを死亡させたが、同弾丸は、Aの身体を貫通し、甲が認識していなかったBにも命中し、Bも死亡した。甲にはA及びBに対する殺人罪の故意が認められる。

No40	故意	正答率
予備H25-7	正解 2、4 (順不同)	69%

1 正しい

最決昭 56.12.21。本記述では、甲の指示が、「Aがこちらの要求を聞き入れなかったら、Aを殺してこい。」という条件付のものであったため、甲にAに対する殺人罪の故意が認められるかが問題となる。判例は、被告人が、A及びBとの間で、被害者らがD方に押し掛け又は喧嘩となるなどの事態になったときは被害者を殺害するのやむを得ないとの殺害の共謀をし、現実には殺害の実行に着手すべき事態については、Aら現場に赴く者の状況判断に委ねられたという事案において、「謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする被告人の意思そのものは確定的であつたのであり、被告人は被害者の殺害の結果を認容していたのであるから、被告人の故意の成立に欠けるところはない」としている。本記述では、甲は、Aの殺害を、Aが甲らの要求を聞き入れなかったらという一定の事態の発生にかからせていたものの、甲がA殺害の計画を遂行しようとする意思は確定的であり、乙のA殺害という結果を認容していたといえる。よって、甲にはAに対する殺人罪の故意が認められる。

2 誤っている

最判昭 60.3.28 (百選Ⅱ86 事件)。本記述では、建造物等以外放火罪の故意が認められるためには、公共の危険の発生の認識が必要であるかが問題となる。判例は、Aが配下のBほか数名の者に、Cの単車の焼損を命じたところ、BらがC方の庭においてCの単車に火を放ち同車を焼損するとともにC方に延焼させたという事案において、「刑法 110 条 1 項の放火罪が成立するためには、火を放つて同条所定の物を焼燬する認識のあることが必要であるが、焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを認識する必要はない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、110 条は結果的加重犯の規定と解すべきであり、条文解釈上も自然であること、結果的加重犯の重い結果の認識は、故意の成立にとって不要であるということを挙げている。本記述では、甲は、他人の所有する自動車に放火して焼損する認識があるので、公共の危険の発生の認識がなくとも甲に建造物等以外放火罪の故意は認められる。

3 正しい

最判昭 23.3.16 (百選Ⅰ41 事件)。本記述では、甲には盗品等有償譲受け罪について確定的な故意はないところ、そのような甲に盗品等有償譲受け罪の故意が認められるかが問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、「赃物故買罪〔注：盗品等有償譲受け罪〕は赃物〔注：盗品等〕であることを知らずこれを買受けることによって成立するものであるが、その故意が成立する為めには必ずしも買受くべき物が赃物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は赃物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思（いわゆる未必の故意）があれば足りる」とし、「たとえ買受人が売渡人から赃物であることを明に告げられた事実が無くても苟くも買受物品の性質、数量、売渡人の属性態度等諸般の事情から『或は赃物ではないか』との疑を持ちながらこれを買受けた事実が認められれば赃物故買罪が成立する」としている。本記述では、甲は、「乙が盗んできたものかもしれない」と盗品性について疑いを持ちながら買い取っており、甲に盗品等有償譲受け罪の故意が認められる。

4 誤っている

最決平2.2.9（百選I40事件）。本記述では、身体に有害で違法な薬物類であるとの認識はあったものの、覚せい剤や麻薬ではないと認識して、覚せい剤が含まれている錠剤を所持していた甲に、覚せい剤取締法違反の罪の故意が認められるかが問題となる。判例は、日本への持ち込みが禁止されている「化粧品」を腹巻内に隠し運搬するように依頼され、外部からの手触りで粉末状のものと分かりつつ、覚せい剤を日本へ密輸入したという事案において、「被告人は、本件物件を密輸入して所持した際、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあった」として、「覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはない」としている。本記述では、甲は、身体に有害で違法な薬物類であるとの認識はあったものの、覚せい剤や麻薬類ではないと認識しており、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識はなかったといえる。よって、上記判例の立場によれば、甲に覚せい剤取締法違反の罪の故意は認められない。

5 正しい

最判昭53.7.28（百選I42事件）。本記述では、甲に、Aに対してのみならずBに対する殺人罪の故意も認められるかが問題となる。判例は、強盗犯人が殺意をもって被害者に暴行を加えたところ、被害者を殺害するに至らず、傷害を負わせたにとどまり、他方で、その予期しなかった第三者に対しても傷害の結果を生じさせた事案において、「犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもつて足りる」とし、「人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかつた人に対してその結果が発生した場合にも、右の結果について殺人の故意があるものというべき」としている。本記述では、Aに対する殺人罪とBに対する殺人罪とは「人を殺した」（199条）という法定の範囲内で符合しているので、甲には、Aに対する殺人罪の故意のみならずBに対する殺人罪の故意も認められる。